

1500309-17.2022.8.26.0279

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FÁBIO APARECIDO TIRONI

Comarca: Itararé

Foro: Foro de Itararé

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... o denunciado estava se dedicando ao tráfico de drogas nesta urbe. No dia em questão, os guardas municipais receberam a notícia de que no local acima citado estava ocorrendo a prática do tráfico de drogas. Com a finalidade de verificar a veracidade da informação recebida, os guardas municipais se valeram de um drone, que captou as imagens do denunciado vendendo drogas para o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itararé

Foro de Itararé

2ª Vara

Rua Frei Caneca, 982, Itararé - SP - cep 18460-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500309-17.2022.8.26.0279 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500309-17.2022.8.26.0279

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Diogo Henrique da Silva

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FÁBIO APARECIDO TIRONI

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de DIOGO HENRIQUE DA SILVA, já qualificado nos autos em epígrafe, que apura a suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Segundo consta na denúncia de fls. 78-81, no dia 28 de abril de 2022, por volta das 14h45min, na Rua Davina Melo Monteiro, nº 150, Vila Novo Horizonte, nesta cidade e comarca de Itararé, DIOGO HENRIQUE DA SILVA, vendeu cinco porções de cocaína, que pesavam 3,79g, e tinha em depósito duas porções de maconha, que pesavam 28,35g, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Sustentou o Ministério Público que "(...) o denunciado estava se dedicando ao tráfico de drogas nesta urbe. No dia em questão, os guardas municipais receberam a notícia de que no local acima citado estava ocorrendo a prática do tráfico de drogas. Com a finalidade de verificar a veracidade da informação recebida, os guardas municipais se valeram de um drone, que captou as imagens do denunciado vendendo drogas para o condutor de uma camionete de cor branca, no caso, a

testemunha Murilo. Assim sendo, deslocaram-se para o local e abordaram Murilo na direção de seu veículo. Nele, encontraram as cinco porções de cocaína, ao passo que Murilo apontou o local onde havia adquirido as porções. Os guardas foram ao local e lá encontraram o denunciado, já conhecido nos meios policiais, inclusive, pela prática do crime de tráfico. Assim, considerando as informações pretéritas, corroboradas pelos relatos de Murilo, os guardas abordaram o denunciado, que apontou o local onde estava o restante da droga, do tipo maconha. O denunciado, informalmente, confessou ser traficante e o proprietário das drogas apreendidas. Portanto, considerando as circunstâncias em que se deu a abordagem do réu e a apreensão das drogas, a quantidade delas, notadamente já fracionadas para a pronta entrega ao consumo de terceiros, tudo permite concluir que o material apreendido era destinado para a entrega ao consumo de terceiro.”.

Preso em flagrante no dia dos fatos (fls. 01-02), o flagrante foi convertido em preventiva em audiência de custódia realizada no dia seguinte (fls. 34-36).

O Ministério Público ofereceu denúncia em 03.06.2022 (fls. 78-81).

No dia 07.06.2022 foi determinada a notificação do réu para os fins do art. 55 da Lei 11.343/06 (fls. 83-84). Na oportunidade foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 26.07.2022.

O denunciado apresentou defesa preliminar por intermédio de defensor dativo (fls. 132-133).

A denúncia foi recebida no dia 27.06.2022 (fl. 137).

O réu foi notificado (fl. 149).

Em audiência virtual realizada na forma do Comunicado CG nº 284/2020, bem como com base no permissivo do art. 6º, § 2º da Resolução nº 312/2020 do Conselho Nacional de Justiça, foi produzida prova testemunhal e o réu foi interrogado.

Em sede de alegações orais o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, ao passo que a Defesa requereu a aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a fixação da pena no mínimo legal.

É o relatório, no essencial. Passo a fundamentar e a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

De início, não há que se falar em nulidade pelo fato de o flagrante ter sido efetuado pela Guarda Civil Municipal, uma vez que nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender alguém em flagrante se estiver praticando crime.

Aliás, não sendo esta atividade privativa dos policiais civis ou militares, foi regular a atuação dos guardas, que surpreenderam o réu em evidente flagrante do crime de tráfico de drogas, infração que enseja situação de flagrante, a ponto de justificar a prisão.

Ademais, com o advento da Lei nº 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, houve regulamentação e ampliação das funções desses agentes públicos, eliminando qualquer discussão acerca da restrita interpretação dada ao art. 144, § 8º, da Constituição Federal.

Portanto, se nos termos do art. 5º do referido Diploma Legal, os guardas civis foram autorizados a colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas, que contribuam com a paz social e em casos de flagrante – o que inclui a abordagem e revista de pessoas, em razão de fundada suspeita – não há falar em qualquer ilegalidade na prisão.

Nesse sentido: “Habeas corpus – Tráfico de drogas – Revista pessoal e flagrante realizado por guardas municipais – Crime permanente – Possibilidade – Exegese do art. 301, do Código de Processo Penal – Precedentes – Art. 144, § 8º, da Constituição Federal regulamentado pela Lei nº 13.022/2014 – Nulidade – Inocorrência; Habeas corpus – Prisão em flagrante – Conversão em preventiva – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Decisão bem fundamentada – Expressiva quantidade de drogas apreendidas – Paciente que foi preso recentemente pelo mesmo delito – Medidas cautelares insuficientes no caso concreto – Liberdade provisória em razão da disseminação da covid-19 – Impossibilidade – Constrangimento ilegal – Não caracterização – Ordem denegada”. (TJSP; Habeas Corpus Criminal

2116359-67.2021.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/07/2021; Data de Registro: 19/07/2021).

Assim, presentes as condições da ação e não havendo preliminares e prejudiciais a serem apreciadas, passo à análise do mérito.

De início, é sabido que o tipo objetivo do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

Na situação ora em apreço, consigne-se, desde já, que as provas constantes dos autos são bastantes a fundamentar um juízo condenatório.

Com efeito, o auto de exibição e apreensão de fls. 18-19 demonstra que foram apreendidas na posse do réu 24,55g (vinte e quatro gramas e cinquenta e cinco centigramas) de "maconha" acondicionadas em 02 (duas) "trouxinhas de papel"; 3,69g (três gramas e sessenta e nove centigramas) de "cocaína" acondicionadas em 05 (cinco) "pinos", além de R\$ 2,00 (dois reais) em dinheiro.

Anote-se que, conforme conclusões dos laudos periciais de fls. 66-69 e 70-73 constatarem tratar-se de substância entorpecente as matérias apreendidas (art. 50, § 1º, da Lei nº 11.343/06), quais sejam, "cocaína" e "tetrahydrocannabinol".

Referidas provas demonstram, além de qualquer dúvida razoável, a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra além de qualquer dúvida razoável que o acusado DIOGO HENRIQUE DA SILVA foi o autor do crime descrito na denúncia, conforme será devidamente demonstrado a seguir.

Com efeito, as provas colhidas durante a instrução processual e elementos informativos angariados na fase inquisitorial são bastantes a fundamentar um juízo condenatório.

A testemunha FELIPE TADEU PROENÇA GATTI, Guarda Municipal que realizou a prisão em flagrante do réu, na fase inquisitorial declarou (fl. 03): "o depoente é guarda civil municipal na cidade de Itararé, e na tarde de hoje sua equipe recebeu uma denúncia anônima de um transeunte que estava ocorrendo a venda de drogas na rua Davina Melo Monteiro, em frente ao numero 150, e o local é conhecido pelos meios policiais pela pratica de venda de drogas, seria um individuo loiro, estatura baixa e camiseta azul, e foi solicitado o apoio aéreo da viatura 30, com uso de drone, e no momento em que adentraram o depoente com a VTR 29 na companhia do GCM Cristiano, recebeu comunicação que na vila a vtr 30 drone flagrou a venda de drogas do referido individuo denunciado a um outro dentro de uma caminhonete de cor branca, e a seguiram para o local e quando estavam adentrando a vila deram de frente com tal caminhonete saindo, então abordaram a mesma, e o condutor da caminhonete Murilo confirmou que havia comprado cinco pinos de droga tipo cocaína pela quantia de R\$50,00, e mostrou que a droga estava no banco da caminhonete, deixaram o mesmo com uma equipe e seguiram até o local indicado, e quando chegaram até o local o individuo que havia vendido a droga, estava transitando a pé na rua, em direção a sua equipe de GMs e foi abordado, e falaram para ele " a casa caiu" e o mesmo confessou que realmente estava vendendo e indicou que tinha mais droga próximo a um muro, e foram encontradas duas porções de maconha uma maior e outra menor, e o mesmo confessou que era dele. Indagado sobre a cocaína ele falou que tinha acabado. Que o mesmo já é conhecido dos meios policiais, e já foi conduzido menor de idade umas três vezes pela mesma prática, e agora maior foi a primeira vez. Foram então os mesmos conduzidos até o plantão policial. Esse equipamento aéreo, fotografou toda a ação. Que afirma que o drone tem autorização da ANAC para ser utilizado, mas não sabe dizer se tem autorização judicial para o tipo de serviço que foi feito. Que não sabe o que é ação controlada judicial, a única coisa que informa é que existe autorização da ANAC. Em tempo, em obediência ao art. 304 do CPP, emprestou a Autoridade, neste ato, RECIBO pela entrega do(s) capturado(s), determinando, com os recursos disponíveis (ressalvada a hipótese de colaboração espontânea de outras instituições) a custódia do(s) agente(s) em dependência designada, dotada de suficiente vigilância acauteladora para ulterior

encaminhamento ao sistema prisional.".

Em juízo aduziu que: "a equipe estava realizando patrulhamento quando receberam denúncia anônima de morador do local que relatou que um indivíduo que estava trajando camiseta azul, bermuda preta, olhos azuis, tatuagem no rosto, estava traficando no local; diante dessa notícia acionaram a viatura 30 que realiza o patrulhamento aéreo e entrou juntamente com a viatura terrestre na Vila Novo Horizonte; a viatura aérea entrou no local e flagrou o tráfico para o condutor de uma camionete branca; fizeram a abordagem do condutor da camionete e encontraram as drogas com ele; ele admitiu que havia adquirido as drogas; fizeram buscas e encontraram o réu; na abordagem o réu confessou a traficância; próximo a ele encontraram mais duas porções de maconha, que ele admitiu que eram dele e destinadas ao tráfico; diante do fato fizeram o flagrante e levaram para a delegacia; conhecia o réu e a sua mãe, que também foi presa por tráfico; o réu já é conhecido nos meios policiais; ele disse que já havia um tempo que ele estava traficando diante da situação que estava vivendo, pelo fato de sua mãe ser usuária de drogas;

No mesmo sentido foi seu colega de farda CRISTIANO AFONSO PROENÇA que na fase policial declarou que (fl. 05): "o depoente é guarda civil municipal na cidade de Itararé, e na tarde de hoje sua equipe recebeu uma denúncia anônima de um transeunte que estava ocorrendo a venda de drogas na rua Davina Melo Monteiro, em frente ao numero 150, e o local é conhecido pelos meios policiais pela pratica de venda de drogas, seria um individuo loiro, estatuara baixa e camiseta azul, e foi solicitado o apoio aéreo da viatura 30, com uso de drone, e no momento em que adentraram o depoente com a VTR 29 na companhia do GCM GATTI, recebeu comunicação que na vila a vtr 30 drone flagrou a venda de drogas do referido individuo denunciado a um outro dentro de uma caminhonete de cor branca, e a seguiram para o local e quando estavam adentrando a vila deram de frente com tal caminhonete saindo, então abordaram a mesma, e o condutor da caminhonete Murilo confirmou que havia comprado cinco pinos de droga tipo cocaína pela quantia de R\$50,00, e mostrou que a droga estava no banco da caminhonete, deixaram o mesmo com uma equipe e seguiram até o local indicado, e quando chegaram até o local o individuo que havia vendido a droga, estava transitando a pé na rua, em direção a sua equipe de GMs e foi abordado, e falaram para ele "a casa caiu" e o mesmo confessou que realmente estava vendendo e indicou que tinha mais droga próximo a um muro, e foram encontradas duas porções de maconha uma maior e outra menor, e o mesmo confessou que era dele. Indagado sobre a cocaína ele falou que tinha acabado. Que o mesmo já é conhecido dos meios policiais, e já foi conduzido menor de idade umas três vezes pela mesma prática, e agora maior foi a primeira vez. Foram então os mesmos conduzidos até o plantão policial. Esse equipamento aéreo, fotografou toda a ação.".

Em juízo asseverou que: "receberam denúncia de um indivíduo traficando no endereço citado; se deslocaram até o local e abordaram uma camionete saindo da vila Nova Horizonte; entrevistaram o conduto, que admitiu ter feito uma compra de drogas no local; localizaram a droga no veículo; ele passou as características da pessoa que havia vendido; foram até o local e avistaram o réu; realizaram a abordagem e o réu confirmou que havia vendido; salvo engano encontraram com o réu algumas porções de droga esverdeada aparentando ser maconha; diante dos fatos conduziram todos os envolvidos; conhecia o réu de vista, já tinha abordado ele; ele não tinha há quanto tempo estava traficando; o condutor da camionete não confirmou se já havia comprado drogas do réu".

A testemunha MURILO FERREIRA MANO, perante a autoridade policial, disse que (fl. 06): "que é usuário de cocaína, faz uso de droga há cerca de quatro ou cinco meses, e se considera viciado. que hoje estava com vontade de usar e foi comprar e comprou de uma pessoa que não conhecida, em um lugar que sabia ser local de venda de drogas, lá chegou e foi atendido pelo outro rapaz aqui conduzido, e comprou do mesmo cinco pinos de cocaína, pagando R\$10,00 cada um, no total de R\$50,00, e quando estava saindo da vila, foi abordado por guardas municipais. Imediatamente confessou que tinha comprado entregou a droga e indicou o local onde havia comprado. Que não acompanhou até o local os GM, e não presenciou eles encontrarem

mais droga do tipo maconha com o indivíduo".

Em juízo contou que: "foi, pegou a droga dele e saiu; nunca teve contato com ele, nem conhecia; reconheceu na hora que era o réu; ele tinha desenho na sobrancelha, até na cara, salvo engano; foi a primeira vez que comprou do réu; comprou do réu R\$ 40,00 ou R\$ 50,00 de cocaína, salvo engano em 05 porções; parou no lugar e o primeiro que foi bater na porta, o primeiro que veio foi ele, o local é ponto de tráfico; estava com uma camionete branca".

Em seu interrogatório perante a autoridade policial o réu DIOGO HENRIQUE DA SILVA exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio, senão vejamos (fl. 10): "O interrogado não possui advogado. Não foi comunicado nenhum familiar e não dispõe de telefone celular de sua mãe para que a mesma seja avisada que está detido nesta delegacia. Não foi agredido durante a abordagem e não ostenta nenhuma lesão corporal, dispensando ser fotografado. Quanto aos fatos, afirma que deseja permanecer em silêncio.".

Interrogado em juízo, por sua vez, o réu confessou a prática dos fatos narrados na denúncia, aduzindo que: "a acusação é verdadeira; estava na esquina; vendeu as 05 porções; avisaram que a polícia estava vindo; foram até o local que estava a droga e apreenderam a maconha que era do depoente; estava traficando há pouco tempo, aproximadamente um mês; cada porção era R\$ 10,00; não ganhava muito; no mesmo tempo que ganha dinheiro, usava a droga; a mãe do depoente é usuária, não tinha outra alternativa, começou a traficar".

Pois bem.

Dos depoimentos acima transcritos se extrai, além de qualquer dúvida razoável, que o réu praticou o crime de tráfico de drogas descrito na denúncia na denúncia. Com efeito, conforme se infere dos autos, no dia 28 de abril de 2022, por volta das 14h45min, na Rua Davina Melo Monteiro, nº 150, Vila Novo Horizonte, nesta cidade e comarca de Itararé, DIOGO HENRIQUE DA SILVA, vendeu cinco porções de cocaína, que pesavam 3,79g, e tinha em depósito duas porções de maconha, que pesavam 28,35g, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Nesse sentido, aliás, foram as declarações dos Guardas Municipais FELIPE TADEU PROENÇA GATTI e CRISTIANO AFONSO PROENÇA, tanto em juízo quanto em solo policial, que de forma harmônica e coerente confirmaram que abordaram um usuário que havia comprovado drogas do réu, bem como que este admitiu a traficância.

Some-se a isso o teor do depoimento da testemunha MURILO FERREIRA MANO que confirmou que adquiriu 05 porções de cocaína do réu por aproximadamente cinquenta reais.

Ademais, o próprio réu confessou a posse das drogas e a traficância.

Além disso, as imagens capturas pela Guarda Municipal (fls. 125-126) corroboram a tese veiculada na inicial acusatória.

Vale ressaltar, outrossim, que as circunstâncias do encontro das substâncias entorpecentes, além do que já se expôs, geram a convicção da posse voltada para o comércio e não a finalidade para o uso próprio.

No que tange ao depoimento de guardas municipais, ressalta-se não existir dispositivo legal vedando ao agente público servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os milicianos, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres, apresentariam testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, têm os funcionários públicos a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente.

Importante ressaltar que o policial é testemunha como outra qualquer, já que não figura entre os impedidos ou suspeitos, sujeitando-se ao compromisso de dizer apenas a verdade, sob as penas do falso testemunho. Ademais, nos casos de tráfico de drogas, onde o testemunho civil é quase sempre impossível, deve ser conferido às declarações do policial o merecido valor em confronto com os demais elementos de convicção trazidos aos autos.

Nessa linha de raciocínio, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que "o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia

probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

O Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende que "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal". (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma).

Vale ressaltar, outrossim, que nada de concreto foi trazido pela defesa que afastasse a credibilidade dos depoimentos dos Guardas Municipais.

Ademais, as circunstâncias do encontro das substâncias entorpecentes, além do que já se expôs, geram a convicção da posse voltada para o comércio e não a finalidade para o uso próprio. Nessa mesma ordem de ideias, conforme trecho do v. acórdão proferido na Apelação nº 0000926-20.2016.8.26.0616, "Por outro lado, o crime de tráfico de entorpecentes é de perigo abstrato, punindo-se a conduta pelo risco que ele representa para a saúde pública, de modo que não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito substância entorpecente com finalidade de venda". (TJSP; Apelação 0000926-20.2016.8.26.0616; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/07/2018; Data de Registro: 03/08/2018).

Ainda, em consonância com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a caracterização do crime de tráfico e drogas prescinde que o réu seja surpreendido no momento da realização da mercancia da droga, especialmente porque o tipo penal é misto alternativo e a prática de qualquer conduta do núcleo do tipo caracteriza do delito. A propósito: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (TJSP - AC 20.239 - Rei. Geraldo Gomes-RT 584/347); "TÓXICOS - Tráfico - Prova de algum ato de comércio - Desnecessidade - Trazer consigo ou manter a droga em depósito para venda, ainda que futura - Suficiência, na medida em que a consumação do delito não exige qualquer resultado Recurso parcialmente provido para reduzir as penas impostas e estabelecer o regime inicial fechado." (Apelação Criminal n. 1.141.860-3/6 São Paulo 5ª Câmara Criminal Relator: Pinheiro Franco 14.02.08 V.U. Voto n. 10.277).

Diante do exposto, resta afastada a tese de desclassificação do delito de tráfico para o de posse de drogas para consumo pessoal (Lei 11.343/06, art. 28) por não encontrar respaldo no acervo probatório dos autos. De fato, da análise detida dos elementos constantes no processo, extrai-se o juízo de certeza acerca da finalidade mercantil, consoante até aqui minuciosamente fundamentado.

À vista de todos esses elementos, conclui-se que o réu DIOGO HENRIQUE DA SILVA, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticou os fatos descritos na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Conforme a teoria da indiciabilidade ou da ratio cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao réu trazer aos autos ao menos a dúvida fundada quanto à presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

No caso sob julgamento, contudo, o réu sequer alegou a existência de causas excludentes da ilicitude.

Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Quanto à culpabilidade, está analisada à luz da teoria normativa pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto ao autor, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta

diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Destaco que o réu sequer suscitou a existência de dirimentes. Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, porquanto o réu é imputável e dotado de potencial consciência da ilicitude, bem como lhe era exigível conduta diversa.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do réu DIOGO HENRIQUE DA SILVA pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, é inerente ao tipo penal; b) Antecedentes: trata-se de acusado sem antecedentes criminais na forma da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não poderá ser considerada negativa; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida do acusado em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade do réu, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo e suas circunstâncias não fogem do ordinário; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o crime foi praticado não excedem o que se espera em condições normais; g) Consequências do crime: do mesmo modo as consequências, que são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão; h) Comportamento da vítima: trata-se de crime sem vítima determinada, motivo pelo qual tal circunstância será valorada como neutra; i) Natureza e a quantidade da droga: são normais à espécie. Assim, diante da ausência de circunstâncias negativas, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes. Presente, contudo, a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), uma vez que o réu era menor de 21 anos de idade na época dos fatos (nascido em 09.07.2003), bem como a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d"). No entanto, a pena intermediária não pode ficar abaixo do mínimo legal nos termos da Súmula nº 231 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas. Consigne-se que atos infracionais praticados pelo agente quando adolescente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar, na análise do caso concreto, dedicação a atividades criminosas e, por conseguinte, impedir a incidência do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. No caso dos autos, conforme informações de fls. 10-11, o réu registra diversas anotações por atos infracionais, inclusive com aplicação de medida socioeducativa de internação por meio de sentença definitiva em razão da prática de atos infracionais análogos ao crime de furto qualificado (autos nº 1500392-72.2018.8.26.0279 e nº 1500641-23.2018.8.26.0279). Além disso, também há notícia do seu envolvimento recente com o tráfico de drogas (autos nº 1503562-47.2021.8.26.0279). Nesse cenário, infere-se a partir de elementos concretos que o réu é pessoa dedicada a atividades criminosas, razão pela qual não faz jus a minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

Considerando que o tempo de prisão provisória não alteraria o regime prisional, deixo de realizar a detração (CPP, art. 387), devendo eventual progressão de regime ser analisada pelo juízo da execução, sobretudo diante da necessidade de aferir a presença dos requisitos subjetivos.

Impede salientar, por fim, que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que são inconstitucionais as previsões da Lei 11.343/06 que impõem a adoção obrigatória do regime inicial fechado e a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo serem observadas as regras do Código Penal quanto ao ponto. Assim, nos termos dos

art. 33, §§2º e 3º do Código Penal, e levando em consideração a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma legal, fixo o regime SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena. Diante da quantidade da pena, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão de sursis (CP, arts. 44 e 77).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para o fim de CONDENAR o réu DIOGO HENRIQUE DA SILVA pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 às penas de 05 anos de reclusão a ser cumprida no regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa no valor individual de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. CONDENO o sentenciado ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 804).

4.2. Conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, diante da subsistência dos motivos já expostos nas decisões anteriores e por entender presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada. Com efeito, o fumus comissi delicti decorre da própria procedência da pretensão punitiva veiculada na denúncia, havendo prova da materialidade e indícios de autoria do crime atribuído ao réu. O periculum libertatis, por sua vez, é evidenciado pela gravidade em concreto do crime praticado pelo réu, da possibilidade concreta de o réu voltar a delinquir, bem como da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que não existem garantias de que em liberdade não se afastará do distrito da culpa. Vale ressaltar, sobre outro aspecto, que "A prisão preventiva pode ser mantida por ocasião da sentença condenatória recorrível que aplicou o regime semiaberto para o cumprimento da pena, desde que persistam os motivos que inicialmente a justificaram e que seu cumprimento se adeque ao modo de execução intermediário aplicado. De fato, não é razoável manter o réu constrito preventivamente durante o desenrolar da ação penal e, por fim, libertá-lo apenas porque foi agraciado com regime de execução diverso do fechado, permitindo-lhe que, solto, ou mediante algumas condições, aguarde o trânsito em julgado da condenação. Sufragar tal entendimento vai contra ao já sedimentado tanto no STF quanto no STJ, no sentido de que, quando presentes as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, "Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade" (STF, HC 89.089-SP, Primeira Turma, DJ de 1º/6/2007). Por outro lado, tendo em vista a imposição do regime semiaberto na condenação, se faz necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o aludido modo de execução, sob pena de estar-se impondo ao condenado modo mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade. Precedentes citados: RHC 39.060-RJ, Quinta Turma, DJe 10/3/2014; e HC 244.275-SP, Sexta Turma, DJe 18/3/2013". (RHC 53.828-ES, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 14/4/2015, DJe 24/4/2015). Isto posto, EXPEÇA-SE guia de execução provisória, devendo a execução ser imediatamente adequada ao regime semiaberto, salvo se preso preventivamente e/ou em regime fechado por outro motivo. Além disso, ANOTE-SE a revisão da prisão no sistema SAJ, notadamente para futura reapreciação, devendo a Serventia observar o disposto no COMUNICADO CG nº 78/2020.

4.3. Considerando a demonstração de que o dinheiro apreendido é produto do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 91, II, "b", do Código Penal c/c art. 63, I, da Lei 11.343/06, como efeito secundário da condenação, DECRETO o perdimento em favor da União dos valores apreendidos nas fls. 18-19. Com o trânsito em julgado da presente sentença, PROCEDA-SE a reversão da quantia em favor do FUNAD.

4.4. DEIXO DE ARBITRAR o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, previsto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido expresso acerca do montante a ser ressarcido, bem como, por consequência, da ausência de contraditório acerca da matéria.

4.5. COMUNIQUE-SE a condenção ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ), e com o trnsito em julgado intime-se o réu para pagamento das custas judiciais (art. 479, das NSGCJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE Certidão de Sentença, extraída na forma do artigo 164 da Lei nº 7.210/84 e artigos 479-B e 480-A das NSCGJ. Expedida a Certidão, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público, para que, querendo, proponha a competente ação de execução da pena de multa na Vara das Execuções Criminais. Após, deverá a z. Serventia lançar a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal". I. Comunicado pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, deverá a z. Serventia proceder à anotação no histórico de partes do evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução e lançando a movimentação "Cód. 61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", arquivando-se a seguir. II. Não havendo comunicação pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, aguarde-se o transcurso do lapso prescricional. Após, volvam-me os autos cls. para declaração da extinção da pena.

4.6. DETERMINO a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas (art. 72, da Lei nº. 11.343/2006), caso a providência já não tenha sido adotada.

4.7. Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ).

4.8. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Itararé, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA